

1500786-18.2021.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, . - São Roque

CEP: 12570-000 - Aparecida - SP

Telefone: (12) 3105-3352 - E-mail: aparecida2@tjsp.jus.br

1500786-18.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500786-18.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS, como incurso na prática dos delitos tipificado(s) no Artigo 33, caput, da LEI Nº 11.343/2006, e artigo 329, caput, do CÓDIGO PENAL, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma penal.

Narra a denúncia que, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 15h37, na Rua Benedito Lino, nº 405, FREI GALVÃO, POTIM, COMARCA DE APARECIDA, ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS GOMES, qualificado às fls. 3, 9/10, 11/12 e 14/15, trazia consigo, para fins de comércio ilícito, drogas, consistente em 2 (dois) microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína e 21 (vinte e um) microtubos contendo crack (droga derivada da cocaína) – vide auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial provisório de fls. 22/24 – sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS GOMES, qualificado às fls. 3, 9/10, 11/12 e 14/15, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada contra os policiais militares Carlos Eduardo Ferreira Sholl de Freitas Lima e Lucas Daniel Joaquim Ferreira, competentes para executá-lo.

Segundo o apurado, o denunciado deliberou praticar o tráfico de drogas, postando-se no local supracitado – já conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes – em um terreno baldio com mato. Para tanto, ele trazia consigo, no interior de um saco plástico, as porções de cocaína e de crack, embaladas individualmente.

Ocorre que, policiais militares, durante patrulhamento de rotina naquele lugar, avistaram o DENUNCIADO no citado terreno baldio, em pé. Ao perceber a aproximação da viatura, ARIEL dispensou algo ao solo e saiu caminhando pela via.

Os policiais foram em direção ao denunciado que, então, tentou empreender fuga correndo. ARIEL foi alcançado na rua Oswaldo Moraes de Castro, rua onde reside. Ao ser detido, o denunciado entrou em luta corporal os agentes da lei. Diante disso, várias pessoas juntaram no local, inclusive familiares dele, que passaram a filmar a ação policial. Ato contínuo, os milicianos solicitaram reforço de outras equipes, tendo sido necessário o uso de espargidor de gás de pimenta para dispersar a multidão. Após isso, o denunciado foi contido e algemado.

Os policiais retornaram então ao local onde viram o DENUNCIADO dispensar algo, sendo ali encontrado o saco plástico contendo 21 microtubos contendo crack (3,5g) e 2 microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína (0,37g).

Denúncia recebida em 14 de dezembro de 2021 (fls. 164/166).

Notificado, o réu ofereceu Defesa Prévia às fls. 125/128, alegando sua inocência e apontando a fragilidade de provas existentes.

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, com a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado, apontando a fragilidade de provas; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado nos artigo 33, caput, da LEI N° 11.343/2006, e artigo 329, caput, do CÓDIGO PENAL, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma penal.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado nos crimes previstos nos artigo 33, caput, da LEI N° 11.343/2006, e artigo 329, caput, do CÓDIGO PENAL, na forma do artigo 69, caput, do mesmo diploma penal. Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI n. 11.343/06

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Termo de Depoimento Carlos Eduardo (fls. 09/10), Termo de Depoimento Lucas Daniel (fl. 11), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 22/23), Laudo Constatação Substância Entorpecente (fls. 25/27), Fotografias (fls. 31/46), Relatório Final (fls. 114/115), Laudo Definitivo Toxicológico (fls. 161/163), bem como pela prova oral colhida.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Carlos Eduardo Ferreira Sholl de Freitas Lima declarou em juízo que:

Estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro. O local é conhecido como ponto de

venda de drogas. Deparam-se com o denunciado em um matagal. Ao ver a viatura, ele dispensou algo e fugiu. Foi acompanhado e detido, quando resistiu a abordagem. No local juntou alguns populares e familiares do réu, que tentaram impedir a ação policial, sendo necessário uso moderado da força, apoio policial e gás de pimenta para dispersão da população. Conseguimos detê-lo e algema-lo. Retornaram ao local e encontraram a sacola com os entorpecentes. Foi conduzido a DP; Visualizou o acusado dispensando o objeto ao solo. Tem certeza que é o mesmo objeto que foi apreendido. A testemunha arrolada pelo Ministério Público Lucas Daniel Joaquim Ferreira narrou em audiência que:

Estavam em patrulhamento de rotina pelo local, com seu parceiro Cabo Shool. O local já é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Inclusive havia denuncia de naquele local tinham ameaçado um policial militar de morte. Nesta data, Ariel avistou a viatura, dispensou uma sacola ao solo. Foram tentar abordá-lo, quando ele correu pelo quarteirão, indo ate sua residência. Ele atentou contra os policiais. Conseguiu detê-lo. Visualizou o acusado dispensando o objeto ao solo. Tem certeza que é o mesmo apreendido. Ele empreendeu violência contra a equipe.

A testemunha arrolada pela Defesa Gabriela Lourenço dos Santos Gomes, dispensada do compromisso pela relação de parentesco com o réu (irmã), narrou em audiência que: Estava indo fazer unha, viu seu irmão sendo abordado pelos policiais. Ele não estava com nada e ela foi ver o que estava acontecendo. Os policiais vieram de forma grosseira, jogaram ele pro canto. Disseram que ele estava praticando coisa ilícita. Um dos policiais pisou no pé dela com coturno. O pé ficou inchado e roxo. Os policiais começaram a agredir seu irmão e a população veio para ver o que estava acontecendo. Acionaram outras viaturas jogando gás para todos ao lados. Eles levaram seu irmão para outra rua. De lá disseram que tinha achado drogas com seu irmão. Disseram que iriam prendê-la. Os policiais não a socorreram. A população que a ajudou.

Interrogado, o réu ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS alegou em juízo que:

Os fatos são falsos. Estava dentro de casa, tinha acabado de sair para rua. Estava andando em direção a esquina de casa. Eles vieram para abordar. O policial veio querendo me algemar, sendo que não tinha nada de ilegal. Negou aos policiais, disse que não estava vendendo nada. Tinha passagem, mas não estava envolvido com nada. Os policiais tentaram algemar ele e ele resistiu, não deixou ser algemado. Os policiais empurraram sua irmã. A população viu aquilo tudo e se juntou no local. Chegaram outras viaturas no local e usaram gás de pimenta para dispensar a população. Negou que as drogas apreendidas eram suas. Disse que nunca teve qualquer problema com os policiais que fizeram a prisão.

Cumpr salientar que, a despeito das alegações do acusado, os dois policiais militares, quando ouvidos em juízo sob compromisso de dizer a verdade, narraram, sem deixar qualquer dúvida e em total coesão e harmonia, que o réu Ariel, ao avistar os policiais, dispensou uma sacola plástico contendo os entorpecentes apreendidos e buscou se evadir do local dos fatos. Ao ser detido, o réu resistiu à ordem legal de prisão dada pelos policiais militares, empregando violência física contra os policiais. Na sacola plástica por ele dispensado, foram encontradas 21 pedras de crack e outras 2 porções de cocaína.

No tocante à idoneidade de depoimentos de Policiais Militares, mister ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que

outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Nesta senda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos ." (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97, p. 12.189, in TACRIM - As mais recentes decisões nº 5, Jun/97, p.07

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Portanto, a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a condenação dos acusados, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Ademais, não há que se falar em contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que não entraram em contradição em momento algum.

Além disso, é esse o entendimento dos Tribunais:

"Pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboçar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias nos pontos secundários que são frutos da imperfeição do psiquismo humano" (JUTACRIM, vol. 95/26, rel. Segurado Braz).

"O importante é como nos diz DELLAPIANE, verificar se embora descorando dos detalhes mínimos concorra a final nos pontos essenciais, nas circunstâncias mais importantes do fato que cada uma, isoladamente reconstituiu" (Nova Teoria da Prova - 2ª ed., Ed. Konfino, 1958 - pág. 145).

Ora, como se vê, a versão trazida pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados é lógica e coesa, não trazendo quaisquer elementos que a ponham em cheque. Assim, nada há que se discutir quanto à forma como se deram os fatos.

Ambas as testemunhas confirmaram, de modo coerente e lógico, confirmaram que o réu estava na posse das substâncias e materiais apreendidos.

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos, sobretudo as confissões espontâneas dos acusados em juízo.

Portanto, não há qualquer dúvida que há prova dos autos é FARTA e ROBUSTA no sentido de vincular o acusado à substância entorpecente apreendida (fls. 22/23) e posteriormente periciadas (fls. 25/27).

Se mostra pouco convincente a versão apresentada pelo acusado, de que o material apreendido não lhe pertencia e que os policiais agiram sem qualquer indício. Para ter a versão apresentada pelo acusado como verdadeira este juízo deveria descartar

totalmente a firme e harmoniosa versão apresentada pelas DUAS testemunhas ouvidas em juízo, o que vai de encontro com todo o entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, bem como no âmbito da Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é uníssono em que se deve dar total relevância ao depoimento apresentado pelos policiais responsáveis pelo flagrante e apreensão, porque esses, na qualidade de agentes da lei, gozam de especial credibilidade e presunção de veracidade em seus relatos, especialmente quando estão em harmonia e consonância com as demais provas produzidas, o que é justamente o caso dos autos. Portanto, a prova produzida nos autos é segura e conclusiva, sendo apta a autorizar o decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de drogas quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o réu trazia, guardava e tinha em depósito para a entrega ilícita ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes (cocaína) que causam dependência física e psíquica, para entrega a consumo de terceiro.

Analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada destinava-se ao tráfico, mormente pela quantidade encontrada, pelo local e circunstâncias da apreensão, bem como pela forma de acondicionamento, incompatível com o mero usuário.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

Nesse sentido, a jurisprudência:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das drogas apreendidas, não se discute que os entorpecentes

apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A natureza da drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a as condições de tempo e lugar em que os acusados foram abordados, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e punível, em face de sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

A versão exculpatória apresentada pelo acusado se encontra completamente dissociada do restante do material probatório.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Logo, presentes todos elementos normativo do tipo penal inscrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

DO DELITO DE RESISTÊNCIA - ART. 329, CAPUT, DO CP

Prevê o artigo 329 do Código Penal o crime de resistência: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio"

O crime de resistência envolve uma oposição, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal. O ato deve estar sendo executado, isto porque violência anterior ou posterior ao ato não configura o delito.

Para a configuração do crime, é indispensável que haja conduta ativa, com violência. A simples resistência passiva não gera o crime.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/05), Termo de Depoimento Carlos Eduardo (fls. 09/10), Termo de Depoimento Lucas Daniel (fl. 11), Relatório Final (fls. 114/115), bem como pela prova oral colhida.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Carlos Eduardo Ferreira Sholl de Freitas Lima declarou em juízo que:

Estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Deparam-se com o denunciado em um matagal. Ao ver a viatura, ele dispensou algo e fugiu. Foi acompanhado e detido, quando resistiu a abordagem. No local juntou alguns populares e familiares do réu, que tentaram impedir a ação policial, sendo necessário uso moderado da força, apoio policial e gás de pimenta para dispersão da população. Conseguimos detê-lo e algema-lo. Retornaram ao local e encontraram a sacola com os entorpecentes. Foi conduzido a DP; Visualizou o acusado dispensando o objeto ao solo. Tem certeza que é o mesmo objeto que foi apreendido. A testemunha arrolada pelo Ministério Público Lucas Daniel Joaquim Ferreira narrou em audiência que:

Estavam em patrulhamento de rotina pelo local, com seu parceiro Cabo Shool. O local já é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Inclusive havia denuncia de naquele local tinham ameaçado um policial militar de morte. Nesta data, Ariel avistou a viatura, dispensou uma sacola ao solo. Foram tentar abordá-lo, quando ele correu pelo quarteirão, indo ate sua residência. Ele atentou contra os policiais. Conseguiu detê-lo. Visualizou o acusado dispensando o objeto ao solo. Tem certeza que é o mesmo apreendido. Ele empreendeu violência contra a equipe.

Dessa forma, observa-se que, pela narrativa fática, a conduta do réu se amolda com perfeição ao delito previsto no art. 329, do CP.

A conduta tipificada consubstancia-se em se opor, positivamente, à execução de ato legal, mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (constrangimento moral), contra a pessoa do funcionário executor ou terceiro que o auxiliar, representantes da força pública.

Os atos de resistência devem ser usados para impedir o cumprimento de ordem legal, No caso dos autos, observa-se que o acusado, conforme relato uníssona e coerente das testemunhas policiais, ao perceber que os policiais iriam realizar sua

detenção, resistiu, empregado violência contra ele. Tal conduta, inclusive, ensejou uma aglomeração de pessoas no local, sendo necessário o apoio de outras viaturas de polícia para conter os populares que se amontoaram no local.

O crime de resistência restou plenamente configurado nos autos.

O réu resistiu de modo violento à prisão, apresentando comportamento agressivo contra os policiais (funcionário público), como intuito de se esquivar da prisão (ato legal), de modo que sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 329, do Código Penal.

No mais, não merece acolhimento a tese defensiva de que os atos praticados pelo réu em tentativa de fuga não configuram o delito de resistência, isto porque, conforme muito bem salientado, aquele que pratica violência na tentativa de esquivar da prática de ato legal contra funcionário público incide no delito, sob pena de se cancelar uma suposta autodefesa violenta contra atos manifestamente legais, o que não se coaduna com a ordem jurídica.

Nesse sentido a jurisprudência:

FURTO TENTADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que tentou subtrair coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório pelo furto tentado. RESISTÊNCIA - Havendo oposição mediante violência ou ameaça à execução de prisão legal, configura-se o delito de resistência. (TJSP; Apelação Criminal 0001261-34.2014.8.26.0511; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 26/11/2015; Data de Registro: 28/11/2015)

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Certa a condenação do réu, passo à dosimetria da pena, com atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que o acusado é reincidente, contudo, a fim de evitar bis in idem, tal circunstância será valorada como circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria da pena. Merece valoração negativa a natureza das substâncias entorpecentes encontradas, uma vez que com o acusado, além da variedade, foi encontrada grande quantidade de cocaína sob a forma de crack, que, com é cediço, possui altíssimo potencial de vício e que causa nefastos problemas sociais, tendo, então, potencial devastador sobre os consumidores e, conseqüentemente, toda a sociedade. Contudo, em se tratando de circunstância negativa específica do delito de tráfico de entorpecentes, a valoração negativa incidirá somente em relação a este delito. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como do art. 42, da lei 11.343/06 são normais à espécie de delito. Assim, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 2 (dois) meses de detenção pelo delito tipificado no art. 329, caput, do CP.

Na fase intermediária, segundo sua folha de antecedentes (fls. 61/62), o acusado é reincidente específico no delito de tráfico de drogas (autos 0001662-82.2018.8.26.0126) atraindo a agravante prevista no art. 64, I, do CP. Dessa forma, aumento a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção pelo delito tipificado no art. 329, caput, do CP.

Ainda na terceira e derradeira fase, ao contrário do que requer a combativa defesa, tendo em vista que o acusado é reincidente, inviável o reconhecimento do redutor de pena da figura privilegiada do tráfico. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosas são CUMULATIVOS, de modo que para o acusado fazer jus a tal causa de diminuição de pena, devem estar presente todos os

requisitos, o que não é o caso do apenado.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, torno-as de definitiva nesse montante.

Considerando que o réu é reincidente e que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP NÃO lhe são inteiramente favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal. Os fatores elencados na primeira fase da dosimetria não permitem a submissão imediata do acusado a regime de menor vigilância afastando, assim, a incidência da Súmula nº 269 do STJ. Deixo de aplicar a detração para fins de fixação do regime prisional, haja vista que perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; confusão que viola os princípios de individualização penal, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição das penas por restritivas de direitos ou a concessão de qualquer outra benesse, tendo em vista que o réu é reincidente em crime doloso, e as circunstâncias do crime, bem como a personalidade do condenado indicam que a substituição não seria suficiente ao atingimento dos objetivos da pena. Sendo o réu reincidente, estando cumprindo pena privativa de liberdade por outro crime, inviável a concessão de Sursis ou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável e suficiente para a justa reprimenda.

O dia-multa, em face da ausência de dados quanto à situação econômica dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado ARIEL LOURENÇO DOS SANTOS GOMES, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do mesmo CODEX, a uma pena de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no menor valor legal, em regime inicial FECHADO pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em REGIME INICIAL SEMIABERTO pelo delito tipificado no art. 329, caput, do CP.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderão recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser reincidente, e que estava em cumprimento de pena quando praticou o fato criminoso pelo qual está sendo sentenciado, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.



Decreto ainda o perdimento da quantia em dinheiro apreendida em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Aparecida, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA